

1500232-33.2021.8.26.0573

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO DE LIMA LUIZ

Comarca: Conchas

Foro: Foro de Conchas

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... quintal; ele assumiu que estava fazendo o tráfico e que trabalhava para o Rodrigo; foi feito contato com a mãe do menor, que morava na vila, e com o padrasto; quando estavam voltando para a viatura, viram o Rodrigo em uma bicicleta, observando o que estava sendo feito; foi abordado e assumiu que estava no tráfico, e aquela noite era apenas o segundo dia que estava tomando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchas

Foro de Conchas

2ª Vara

Rua Goiás, 521, Conchas-SP - cep 18570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500232-33.2021.8.26.0573 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500232-33.2021.8.26.0573

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2212973/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 19473627 - DEL.SEC.BOTUCATU, 816/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2212973 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2212973 - DEL.POL.CONCHAS, 816/21/200 - DEL.POL.CONCHAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO PASCOAL DA SILVA ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO DE LIMA LUIZ

Vistos.

1 O relatório

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Rodrigo Pascoal da Silva Almeida, imputando-lhe a prática do delito previsto nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Narrou a peça acusatória (fls. 115-118) que:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 06 de agosto de 2021, por volta de 23h00, na rua Quinze de Novembro, nº 128, bairro São José, nesta cidade e comarca de Conchas, RODRIGO PASCOAL DA SILVA ALMEIDA, vulgo "Neco", qualificado às fls. 16/17, agindo em concurso de agentes com o adolescente K. V. da S., trouxe consigo, para entrega e consumo de terceiros, 105 (cento e cinco) pinos de cocaína

e 17 (dezesete) pinos de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo pericial de fls. 66/75.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram três indivíduos na praça Tiradentes. Ao avistarem a viatura, dois deles empreenderam fuga para lados opostos e ambos dispensaram uma sacola plástica. Os policiais foram até o local e abordaram Gilcimar Vasques, pessoa que não havia fugido e que admitiu ter adquirido um pino de "crack", por R\$10,00, do denunciado e do adolescente. Em busca pessoal nada encontraram. Além disso, Gilcimar apontou a identidade dos foragidos, afirmando que se trata de "Neco" (RODRIGO) e K..

Continuando as buscas pelo local, os policiais encontraram as duas sacolas deixadas pelo denunciado e pelo adolescente, havendo 93 (noventa e três) pinos de cocaína e 2 (dois) pinos de "crack" na sacola deixada por RODRIGO, além de 12 (doze) pinos de cocaína e 15 (quinze) pinos de "crack" na sacola deixada por K., totalizando 105 (cento e cinco) pinos de cocaína e 17 (dezesete) pinos de "crack", conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09.

Após, em diligências, localizaram o adolescente K. próximo ao cemitério municipal, com a quantia de R\$ 100,00 (cem reais), este que informou ser um dos indivíduos que estava na praça vendendo drogas e seu parceiro era a pessoa de RODRIGO.

Logo avistaram RODRIGO na esquina e, em busca pessoal, encontraram a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais). Aos policiais militares, RODRIGO confirmou a prática delitiva.

A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, aliadas ao relato da testemunha que adquiriu entorpecentes do denunciado e as demais circunstâncias da prisão evidenciaram a finalidade do tráfico.

Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito.

Em decisão de fls. 129-131 foram deferidas diligências e foi determinada a notificação do acusado.

Foi apresentada defesa preliminar às fls. 209-215.

Em decisão de fls. 232-235 foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução.

Realizado o ato, foi (foram): [a] colhidas provas testemunhais (audiência virtual); e [b] interrogados os réus.

Na fase do artigo 402, do CPP, as partes nada requereram.

Após realizaram debates orais (os quais foram gravados), passei à sentença.

2 A fundamentação

2.1 As preliminares

2.1.1 A nulidade pela falta do incidente de insanidade mental

Os arts. 45 e 46 da Lei de Drogas permite que haja isenção ou redução da pena, caso o agente esteja inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento.

No caso, aduz a defesa que há nulidade do processo, porquanto não foi realizado o incidente de insanidade mental por vício de drogas conforme requerido em defesa prévia, o que, inclusive, não seria passível de realização neste momento porquanto a prova já se perdeu no tempo.

Ocorre que, contrariamente ao alegado, nos termos do art. 149 do CPP, "quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal".

O requerimento, na hipótese, foi feito às fls. 213-214, sem menção à situação concreta do acusado. A par disso, nenhum documento foi acostado que permitisse avaliar e concluir por eventual dúvida sobre a sua integridade mental, de modo que não havia qualquer razão para o deferimento.

Assim, não era possível a determinação do incidente de insanidade mental à época, em razão da falta de elementos a tanto, e assim também no presente momento, situação que é indicada pela própria defesa.

2.1.2 A realização da audiência de custódia e a defesa do réu

A previsão da audiência de custódia vem indicada no Pacto Internacional de Direitos

Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, conhecido como Pacto de San José da Costa Rica. Posteriormente, foi proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal, em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, indicando a necessidade de sua realização.

De outro turno, após o advento do Pacote Anticrime, o art. 287 do CPP previu que “se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia” (grifou-se).

Todavia, na hipótese vertente, a apreciação do flagrante se deu por escrito, em decisão de fls. 87-90, em observância à Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, e ao Comunicado n. 232/2020 da CGJ desta Corte, o que, inclusive, constou naquela decisão.

Ademais, segundo o que consta às fls. 16-17, foi o próprio acusado quem se negou a dar sua versão dos fatos na hipótese. Além de que se trata de situação ocorrida durante o inquérito policial.

Desse modo, também não é possível o acolhimento da preliminar aventada.

2.1.3 As teses preliminares

A despeito da falta de apreciação em decisão que marcou audiência, as teses foram apreciadas em audiência, antes de se iniciar as alegações finais. Ademais, não se vislumbra prejuízo, sendo necessário este para decretação de nulidade.

2.2 O mérito

2.2.1 O crime de tráfico de drogas

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Rodrigo Pascoal da Silva Almeida, imputando-lhe a prática do delito previsto nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

A materialidade e a autoria são comprovadas pelos seguintes elementos: [a] auto de exibição e apreensão (fls. 8-9); [b] laudo pericial de fls. 125-127; e [c] depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento.

Conforme laudos periciais produzidos, foram encontrados: [a] 74,28 g (setenta e quatro vírgula vinte e oito gramas), divididos em 105 (cento e cinco) porções, de cocaína; e [b] 9,89 g (nove vírgula oitenta e nove gramas), divididos em 16 (dezesesseis) porções, de cocaína.

Referidas substâncias são consideradas como drogas, nos termos do previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, o qual estabelece considerar-se como tal “as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União”. A lista mencionada foi indicada nos laudos periciais logo após a identificação de cada uma das porções.

No que tange à caracterização do tráfico, vê-se que pela forma em que acondicionadas as substâncias (divididas em várias), além de sua quantidade, 121 (cento e vinte e uma) porções ao total, estavam separadas para venda e posterior consumo.

Com efeito, a separação das drogas no número em que ocorrido, bem como a maneira de seu acondicionamento, denotam que as substâncias seriam utilizadas na venda, notadamente porque, pela quantidade, não é crível que se destinavam a consumo, a despeito das alegações da defesa.

De outro turno, os depoimentos fazem concluir no mesmo sentido.

Gilcimar Vasques aduziu que estava no local dos fatos para comprar drogas; comprou do Rodrigo Pascoal, foi a hora que correram porque a viatura chegou; deu de cara com os policiais, que o abordaram; adquiriu crack e pagou R\$ 10,00; o apelido do Rodrigo é Neco; viu eles entregarem na mão e saírem correndo, foi os policiais que acharam, o depoente não viu; o menor conhecia também só de vista; eles estavam juntos; e passou essas informações para os policiais, que localizaram os dois e os abordaram.

Ouvido em juízo, Camilo Aparecido Miranda, policial militar, disse que na data dos fatos estavam em patrulhamento nas imediações da Vila São José; havia algumas denúncias de tráfico; adentrando a uma via sem saída, visualizaram três indivíduos; a viatura se aproximou e dois deles deixaram uma sacola e correram para cada lado (linha do trem e cemitério); um deles ficou no chão e não levantou; esse foi

abordado e foi identificado como usuário; esse avisou que estavam o Rodrigo, conhecido como Neco, e o menor K.; disse que não conseguiu fugir porque tinha acabado de usar cocaína, e não conseguiu nem levantar da calçada; foram verificar o que deixaram na calçada, eram duas sacolas, contendo cocaína e crack; era uma quantidade bem grande de entorpecentes; conseguiram o apoio de uma segunda viatura que estava na cidade; foi feito contato com eles; sabiam onde moravam o K., e seguiram em sentido à residência deste; ele estava voltando para o local, correu ao ver a viatura e entrou em uma residência; conseguiram abordá-lo em um quintal; ele assumiu que estava fazendo o tráfico e que trabalhava para o Rodrigo; foi feito contato com a mãe do menor, que morava na vila, e com o padrasto; quando estavam voltando para a viatura, viram o Rodrigo em uma bicicleta, observando o que estava sendo feito; foi abordado e assumiu que estava no tráfico, e aquela noite era apenas o segundo dia que estava tomando conta daquele ponto; salvo engano, os dois portavam dinheiro na abordagem, tanto o K. e quanto o Rodrigo; não se recorda exatamente os valores, mas ambos tinham; e K. tinha também um celular.

Leonardo Cardozo Junior, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento, no bairro São José próximo ao cemitério; quando viraram uma rua sem saída e sem asfalto, dois indivíduos empreenderam fuga; conforme a viatura se aproximou, visualizaram um terceiro, que ficou sentado; com esse indivíduo foram encontrados pinos vazios; este, durante a entrevista, informou que havia comprado do Rodrigo Pascoal e do menor de idade de nome K.; ele tinha acabado de usar a droga, então não conseguiu nem se levantar; dito isso, foram aos arredores procurar algum vestígio e localizaram sacolas contendo entorpecentes, no sentido em que os dois indivíduos correram; fizeram diligências e encontraram o menor K., que estava retornando ao local onde aconteceram os fatos; ele correu e entrou em uma residência, em um quintal; ali mesmo foi abordado, e com ele tinha celular e quantia em dinheiro; conforme foram o levando para a viatura, o Rodrigo apareceu de bicicleta e ficou observando; foi abordado também, e confirmou que estava na prática do tráfico, e que fazia uns dois dias que fazia isso; no interior das sacolas havia entorpecentes, mas não sabe precisar a quantidade, mas, a princípio, era bastante; o Rodrigo admitiu a conduta de tráfico; do menor K., não ouviu declaração; não se recorda quanto estava com quem, mas está tudo no boletim de ocorrência; no momento em que entraram na rua, os dois estavam um de cada lado, e o terceiro sentado; quando a viatura iluminou a rua, cada um correu para um lado; nesse momento a fuga não foi com bicicleta; e a bicicleta somente apareceu quando estavam abordando o K.

Interrogado, o réu Rodrigo Pascoal da Silva Almeida gizou que mora no bairro taquari 3; é usuário de crack; foi comprar crack com o K.; acharam R\$ 60,00 com o interrogado, e o abordaram; no automático o prenderam; foi somente para comprar; não chegou a comprar, porque não deu tempo; não correram, pegaram na rua com a bicicleta; não aconteceu o que narraram de estarem na rua e fugir; foi comprar, mas apenas na outra rua, na casa do K.; antes de ir na casa do K., tinha acabado de sair de casa; em casa, tinha jantado, assistido um jogo de futebol; gosta de crack e foi na biqueira por ter R\$ 60,00; estava sozinho em casa, porque mora sozinho; não se recorda que jogo estava assistindo; eram umas 19h00min, 19h30min; tem Sky em casa com TV a Cabo; não se recorda o canal porque já estava louco de drogas; já tinha feito o uso; tinha usado crack; tinha pego o crack do K., em outro dia; não conhecia o K., tinha contato apenas na hora de pegar droga; o contato era feito pelo celular, por ligação; não tem mais o celular; não se recorda o número do celular; não foi ouvido na delegacia de polícia; não deram tempo para dar depoimento, colocaram algema, levaram à delegacia e foram para Botucatu; não chegaram a perguntar o que queria no local; e é a primeira vez que está de frente com um juiz.

Logo, do que se viu, a droga estava preparada para venda e em posse do réu. Ao assim agir, incidiu no disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o qual classifica como crime "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar", devendo incidir nas penas a ele cominadas.

No que toca às alegações da defesa, cabe destacar que, primeiramente acerca da defesa pessoal, que a versão do acusado restou isolada no contexto dos autos. Aduz que estava indo apenas comprar drogas do adolescente K., todavia, há testemunho de pessoa que estava fazendo a aquisição de drogas de ambos (o qual, inclusive, tinha acabado de fazer uso do que foi comprado).

A par disso, não há outros elementos para se concluir pela inocência do acusado. Sua versão não tem qualquer amparo, como dito. Há, apenas, seu próprio interrogatório, dado em juízo, sem outros elementos. A defesa postula o reconhecimento da validade do interrogatório do réu, isso em detrimento do que foi indicado pelas testemunhas, uma delas que era a própria adquirente, e que apontou o acusado, inclusive mencionando o seu apelido.

Contrariamente ao aduzido, não há condenação com base em elementos colhidos na fase investigativa. Tampouco há condenação em virtude de condenações prévias. Há, sim, uma situação fática indicada por testemunhas que estavam no local, em contrapartida à versão isolada do acusado. Veja-se, inclusive, que condenação com base em condenações prévias feriria a lógica processual penal brasileira, em que vige o Direito Penal do Fato, e não do Autor.

Acerca da causa de aumento do art. 40 da Lei de Drogas, qual seja, "sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação" (inciso VI), deve incidir na hipótese, consoante elementos acima já indicados, notadamente as circunstâncias em que realizada a abordagem, em que se encontrava o adolescente K.

Além disso, não há qualquer dúvida sobre a imputabilidade do demandado.

2.3 A dosimetria da pena

No que tange à dosimetria da pena, destaco, na primeira fase (pena-base), que, de acordo com o art. 59 do CP: [a] a culpabilidade (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie; [b] inexistem informações suficientes acerca da conduta social (meio como se comporta no seio da sociedade) ou da personalidade (características pessoais advindas de sua psique); [c] os motivos (as razões de sua prática), as circunstâncias (modo em que ocorreu) e as consequências (situações advindas da prática) também não se apresentam destoantes do que normalmente se espera nesses casos; e [d] não há vítima direta por se tratar de delito vago.

Devem ser valoradas negativamente, entretanto, as circunstâncias referentes aos maus antecedentes (autos de n. 0001730-82.2012.8.26.0145, fl. 266; 1500151-44.2020.8.26.0145, fl. 267; e 0024044-21.2005.8.26.0451, fl. 268) e da natureza e quantidade da droga (em mais de 100 (cem) porções).

Destaco que o feito de n. 1500151-44.2020.8.26.0145 (fl. 267) não pode ser valorado como circunstância ou reincidência, eis que ainda não ocorrido o trânsito em julgado.

Saliento, por oportuno, que: [a] "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula n. 444 do STJ); e [b] "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial" (Súmula n. 241 do STJ).

Assim, majoro a pena em 1/5 (um quinto) e fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase (pena-provisória), destaco a inexistência de agravantes ou de atenuantes.

Saliento que: [a] "a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ), o que, por consequência, também inviabiliza sua majoração além do máximo; [b] nos termos do já destacado acima, "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial" (Súmula n. 241 do STJ); e [c] "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal" (Súmula n. 545 do STJ).

Diante disso, mantenho o mesmo patamar como pena provisória.

Na terceira fase (pena-definitiva), destaco a inexistência de causa de diminuição

de pena, porquanto o agente possui maus antecedentes e não pode ser beneficiado pelo tráfico privilegiado. Há, de outro turno, a causa de aumento referente à prática visando a atingir adolescente, o que enseja a majoração em 1/6 (um sexto), deixando a pena-definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto à detração (art. 387, § 2º, do CPP), entendo que é matéria afeta à execução penal (art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal). Ademais, não alteraria o regime inicial na hipótese.

Estabeleço: [a] como regime inicial, o fechado, em razão do montante da pena e da existência de circunstâncias judiciais negativas (art. 33, §§ 2º, 'a', e 3º, do CP); e [b] o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, § 1º, do CP), notadamente por não haver outros elementos que possam indicar em sentido contrário.

No ponto, cabe destacar que: [a] "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (Súmula n. 440 do STJ); [b] "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula n. 719 do STF); e [c] "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou superior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula n. 269 do STJ).

Em razão do montante da pena, deixo de converter em restritiva de direito ou de realizar sua suspensão condicional da pena.

2.4 A indenização mínima

Deixo de fixar indenização mínima para a hipótese vertente, porquanto não houve pedido expresso nesse sentido na denúncia, o que impede sua concessão, conforme entendimento da Corte de Cidadania (AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

2.5 A prisão preventiva

No mais, deve ser mantida a prisão preventiva dos réus, porquanto convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (*fumus commissi delicti*), risco de liberdade (*periculum libertatis*) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313, do CPP.

Quanto aos demais pressupostos, verifico que: [a] a situação versa sobre crime de doloso com pena máxima superior a 4 (quatro) anos; [b] há prova da ocorrência do fato típico, ilícito e culpável e da autoria do agente, conforme fundamentação desta sentença; e [c] presente o perigo de liberdade (*periculum libertatis*) e insuficientes as medidas alternativas, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

Ademais, a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública (preservação de situação de paz e sensação de segurança), mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa, isso em razão da grande quantidade de drogas e da existência de condenações prévias, inclusive pelo mesmo crime.

Por fim, na hipótese em tela há equilíbrio entre os limites de excesso e insuficiência da medida, porquanto a prisão processual permite assegurar a adequada e razoável repressão da criminalidade, sem, entretanto, destruir o núcleo essencial de direitos fundamentais dos envolvidos.

3 Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal condeno o réu Rodrigo Pascoal da Silva Almeida pela prática do delito previsto nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e de 700 (setecentos) dias-multa, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Contudo, a respectiva exigibilidade está suspensa, durante o prazo extintivo de 5 (cinco) anos, em face da presunção de hipossuficiência financeira, consoante arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC.

Mantenho a prisão preventiva, conforme acima indicado.

Declaro o perdimento de bens apreendidos em nome do acusado em favor da União, os quais podem ser destruídos em razão de sua irrisoriedade.

Destruam-se eventuais drogas ainda existentes.

Fixo a remuneração do advogado dativo no máximo previsto na tabela da DPE/OAB.
Após o trânsito em julgado: [a] comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF; [b] formem-se os autos de execução; e [c] proceda-se às demais determinações de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpridas todas as determinações, arquivem-se.
Conchas, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA